

1522602-71.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... a ação de guardas civis metropolitanos em casos de tráfico de droga já foi pacificada pelos Tribunais Superiores.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MEIOS ILÍCITOS. OBTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE.

GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 301 DO CPP. INTELIGÊNCIA. 1. Qualquer um do povo pode ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522602-71.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522602-71.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Indiciado:

MOACIR BORGES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

MOACIR BORGES DOS SANTOS (RG. n.º 14354331/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 17 horas, durante o estado de calamidade pública (Decretos Estaduais nº 64.881/20 e 65.663/21), na Rua Helvetia, nº 168, Bairro Santa Cecília, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 44 porções de cocaína, com peso total de 46g, e 01 porção de cocaína, com peso total de 504g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se no interior de uma construção abandonada, pronto para entregar as substâncias entorpecentes a terceiros.

Num dado momento, Guardas Municipais realizavam diligência pelo local dos fatos, quando avistaram o denunciado, cercado e interagindo com dependentes químicos, aparentando comercializar drogas com o grupo. Diante disso, os milicianos agentes públicos realizaram a abordagem do acusado.

Em revista pessoal, os Guardas Municipais lograram êxito em apreender, no interior dos bolsos da calça do denunciado, 44 porções de cocaína, além do importe de R\$ 1.670,00. Já nos pés do denunciado, os milicianos apreenderam um saco plástico, no interior do qual havia cerca de 500 gramas de cocaína.

Em solo policial, o réu se manteve em silêncio (fls. 04).

Em 18 de outubro de 2021, foi determinada a notificação do acusado (fls. 135/136) e, nos termos do artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi reservada na modalidade virtual (fls. 144/147). O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Em 24 de novembro de 2021, a denúncia foi recebida e iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou em preliminar, a vinda dos laudos periciais falantes. No mérito, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, manifestou-se pelo não cabimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pela exasperação em razão dos maus antecedentes e reincidência, bem como pela a fixação de regime inicial fechado (fls. 172/173).

Por sua vez, a defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão como atenuante da pena, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a detração e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 173).

Os laudos faltantes foram juntados aos autos e as partes foram devidamente intimadas para ciência e eventual manifestação.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal. Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografia das drogas e do dinheiro (fls. 17), laudo pericial das anotações manuscritas apreendidas (fls.181/186), laudo de constatação (fls. 19/22) e laudo pericial químico-toxicológico (fls. 189/191) que constatou que os materiais apreendidos continham drogas, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa. As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: a quantidade e o tipo de droga, o local e as circunstâncias do flagrante, não autorizam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não sendo o caso de absolvição e tampouco de desclassificação.

Assim, quanto à autoria do delito, a prova dos autos autoriza o decreto condenatório.

Durante o interrogatório policial, o réu MOACIR optou por permanecer silente (fls. 04).

Em Juízo, o réu MOACIR confessou os fatos. Disse que estava com dívida com o traficante e aceitou transportar as drogas e o dinheiro para o traficante. Devia cento e cinquenta reais. É usuário de crack. Não estava vendendo. Estava fumando crack e os usuários estavam a sua volta pedindo para usar. Não tem como comprovar que estava sendo ameaçado. O dinheiro era para ser depositado numa conta na lotérica.

Decididamente, a confissão judicial torna incontroversa a autoria delitiva, mormente porque corroborada pelo restante da prova.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo

confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório. Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos das testemunhas arroladas.

Os agentes da lei, ao contrário do firmado pela defesa, narraram os fatos de maneira convicta, restando claro que narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos.

Os relatos dos guardas civis metropolitanos foram firmes, coerentes e detalhados. Assim, a testemunha STIVE CAMPOS DA SILVA, GCM, em Juízo, reconheceu o réu e narrou que passaram pelo local, perto da Cracolândia, numa construção abandonada, e viram o réu transacionado algo com usuários a sua volta. Resolveram abordá-lo e com ele acharam drogas e dinheiro, bem como perto do pé dele um pacote com quantidade de pó branco. O depoente ficou na segurança. Não ouviu o réu dar qualquer versão. Nos bolsos dele havia diversos papелotes de pó branco e cédulas de dinheiro, num total de R\$ 1.670,00. O réu não parecia drogado. Não o conhecia até a data dos fatos. Da mesma forma, a testemunha RICARDO VIRGILIO SAMPAIO, policial militar, em Juízo, relatou que, em patrulhamento na região da Helvetia, dentro de uma edificação abandonada, perto da Cracolândia, viram pessoas em volta ao réu, pessoas com características de dependentes químicos ou usuários. Fizeram a abordagem e com o réu encontram drogas e dinheiro. Ele tinha sacolés nos bolsos, com cocaína na forma de pó. O dinheiro estava também nos bolsos, diversas notas, a maioria miúdas, cerca de mil e seiscentos reais. Ele ficou em silêncio, bem calmo. Foram abordadas diversas pessoas no fluxo. Viram movimentação típica de transação entre os que estavam em volta do réu e o réu que chamou atenção da equipe. As drogas nos bolsos estavam em pequenas porções e uma porção maior perto do pé dele.

Em suma, os guardas municipais confirmaram, de maneira unânime, os fatos descritos na denúncia, descrevendo que as drogas e os valores estavam na posse do réu e que ele foi flagrado enquanto comercializava drogas a um grupo de usuários.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos agentes públicos é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos seus depoimentos, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Inclusive, a ação de guardas civis metropolitanos em casos de tráfico de droga já foi pacificada pelos Tribunais Superiores.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MEIOS ILÍCITOS. OBTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE.

GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 301 DO CPP. INTELIGÊNCIA. 1. Qualquer um do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito, não obstante a atribuição da Guarda Municipal pela Constituição (ex vi, artigo 144, § 8o. da CF/1988), o que revela a legalidade da hipótese dos autos. Inteligência do art. 301 do CPP.

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 950569 /MS 2016/0183230-4).

Noto, ainda, que na fase policial, a narrativa de ambos foi idêntica, inclusive acerca dos detalhes da ocorrência.

De outro lado, não foram arroladas testemunhas ou apresentadas provas aptas a macular os depoimentos dos guardas municipais.

Neste aspecto, vale atentar que não tem cabimento imaginar que os agentes públicos teriam a possibilidade de deter traficantes e, deliberadamente, imputar ao réu a responsabilidade sobre o entorpecente, apenas e tão somente para prejudicá-lo.

As testemunhas não teriam motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicar o acusado.

No mais, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes públicos não estão proibidos de depor nos processos de cuja fase extrajudicial participaram.

Analisados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Senão vejamos: o réu foi preso em flagrante próximo à Cracolândia, trazendo consigo 44 porções de cocaína, com peso total de 46g, e 01 grande porção de cocaína, com peso total de 504g, além de R\$ 1.670,00, sendo que todos os elementos de prova somados mostram-se meios hábeis e legítimos para sustentar a ocorrência do delito. Sendo assim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais.

No tocante à agravante da calamidade pública, com razão a nobre defesa, pois, como já decidido por nossos Tribunais, a agravante deve ser aplicada levando em consideração a natureza do delito e as circunstâncias da ação delituosa.

Assim, embora o Estado Brasileiro tenha decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos descritos na denúncia, o certo é que a natureza da calamidade em nada facilita a execução do crime em tela, bem como não aumenta a gravidade da conduta.

E, ainda, a natureza do crime, ou seja, o tráfico, não agrava as consequências de tal calamidade.

Como mencionado no V. Acórdão proferido em sede de Apelação Criminal nº 1509934-05.2020.8.26.0228 -Voto nº 13766 TJSP, é "evidente que as circunstâncias previstas na alínea "j" do inciso II do artigo 61 do Código Penal devem ter relação direta com o crime praticado para que possam ser reconhecidas. É o caso, por exemplo, de crime de furto cometido após enchente, quando as casas se encontram abandonadas por seus proprietários, ou de crime de tráfico de pessoas durante migração forçada por desastres naturais, onde claramente se aproveita o autor dos delitos da situação de calamidade para cometer o crime.".

Não é o caso dos autos.

O acusado não obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia do COVID 19, não sendo assim possível reconhecer, in casu, a agravante em questão.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta Maus antecedentes, conforme folha de antecedentes criminais (fls. 124/134) e certidão de objeto e pé (fls. 160/162), cujo conteúdo aponta que, das quatro execuções penais que o réu ostenta, uma ainda está vigente.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, bem como ao art. 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu, principalmente em razão da quantidade de cocaína apreendida, que totaliza 550g.

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social. Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo artigo 59, do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal. Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Assim, a pena será fixada acima do mínimo legal em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, conforme já analisado, deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

De outro lado, compenso a circunstância agravante da reincidência (fls. 124/124 e

160/162) com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem reconhecidas.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu MOACIR BORGES DOS SANTOS (RG. n.º 14354331/SP), qualificado nos autos, à pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Deixo de conceder o sursis penal ou o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos legais.

Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da vida criminal pregressa do acusado e da quantidade da pena, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial FECHADO, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução e, não havendo alterações fáticas que demonstrem a ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, bem como perda do valor apreendido à União, oficiando-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA